

1501194-97.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... o envolvimento da corré Regina no tráfico de drogas praticado pelo acusado, sendo de rigor sua absolvição.

Do mesmo modo, incabível o reconhecimento da causa de aumento referente ao art. 40, III, da Lei de Drogas, visto que o conjunto probatório não revela a prática do tráfico de drogas nas dependências ou imediações de estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: "A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

1501194-97.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ANSELMO PONTES e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

RAFAEL ANSELMO PONTES e REGINA MARIA DE CASTRO FEITOSA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma dos artigos 29, caput, e artigo 35 da Lei nº 11.343/06, ambos combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "j", e na forma do artigo 69 do Código Penal

Segundo a denúncia, no dia 16 de agosto de 2020, por volta de 11h, na Rua João Francisco Vasques, nº 01, Centro, na cidade de Clementina, comarca de Birigui, agindo em conluio e com unidade de desígnios, nas imediações de instituição hospitalar, Rafael Anselmo Pontes e Regina Maria De Castro Feitosa traziam com eles 7,45 g (sete gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína, distribuídos em 60 (sessenta) porções, e tinham em depósito 1,67 g (um grama e sessenta e sete centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, em ocasião de calamidade pública.

Consta também que, de meados de junho de 2020 até o dia 16 de agosto do mesmo ano, na cidade de Clementina, comarca de Birigui, Rafael Anselmo Pontes e Regina Maria de Castro Feitosa associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida às fls. 223/224. Os réus foram devidamente citados, apresentando defesa prévia às fls. 257/260 e 261/263 (Regina e Rafael, respectivamente). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas da acusação, interrogando-se, posteriormente, os réus. (fls. 315/316).

Em alegações finais apresentadas oralmente, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência parcial da acusação, requerendo a absolvição da ré Regina quanto ao delito de tráfico e de ambos os réus quanto ao delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/06. Posteriormente, postulou pela condenação do réu Rafael pelo delito do artigo 33 da Lei de Drogas.

A Defesa, a seu turno, pugnou pela procedência parcial da pretensão inicial e consequente absolvição da ré Regina quanto ao crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, bem como pela absolvição de ambos os réus quanto ao delito previsto no artigo 35 da mesma Lei. Pugnou, ainda, quanto ao réu Rafael, pela possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é parcialmente procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução processual penal, a materialidade do delito de tráfico restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudos de constatação prévia de entorpecentes de fls. 39/40 e 41/42, laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 159/161 e 162/164, laudo de aparelho celular de fls. 186/206, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

Interrogado em Juízo, o réu Rafael confessou a prática do tráfico, relatando que, no dia dos fatos, estava na companhia de Regina e que ambos iriam para a casa de sua mãe. Narrou que durante o trajeto faria a entrega dos entorpecentes em troca de 05 "balinhas" de crack, as quais seriam destinadas ao consumo próprio, eis que era usuário, ocasião em que foi abordado pelos policiais militares. Acrescentou que colocou as drogas na bolsa de Regina para realizar a troca posteriormente. Indagado, afirmou ter praticado o delito durante aproximadamente 03 semanas.

Por sua vez, a corré Regina negou a prática do crime, narrando que na ocasião se dirigia ao hospital na companhia de Rafael para visitar uma amiga, momento em que avistaram a viatura. Na oportunidade, Rafael informou à depoente que havia colocado drogas em sua bolsa. Em seguida, ingressaram no hospital para aguardar, porém foram surpreendidos pelos policiais militares, que realizaram revista pessoal, encontrando os entorpecentes.

Indagada, a depoente afirmou que Rafael era usuário de drogas e que as vendia

entorpecentes apenas para pagar a dívida que havia contraído em razão do consumo de entorpecentes, e que já o fazia por aproximadamente 08 meses.

A testemunha Fernanda Nanartoris, policial militar, relatou que estava em patrulhamento, quando próximo ao local dos fatos avistou um casal, que ao perceber a presença da viatura demonstrou nervosismo, entrando apressadamente no saguão do hospital. A depoente entrou logo em seguida, oportunidade em que Regina dirigiu-se ao banheiro e Rafael permaneceu sentado, dando ordem para que ambos permanecessem parados. Ao realizar revista pessoal, encontrou 60 invólucros de substância que aparentava ser crack na bolsa de Regina.

Posteriormente, a testemunha indagou Regina quanto à origem dos entorpecentes, tendo a ré alegado que desconhecia e que só soube no momento em que avistou a viatura e foi informada por Rafael, afirmando que havia mais drogas em sua residência e, sucessivamente, franqueando a entrada dos policiais militares. A depoente afirmou que encontrou 01 porção de maconha e a quantia aproximada de R\$ 300,00 (trezentos reais) em notas diversas no imóvel.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Michael Ricardo Gomes, policial militar, acrescentando que conhecia o réu Rafael dos meios policiais mediante denúncias sobre tráfico de drogas, as quais não citavam Regina.

Pois bem. Conforme sobressai do conjunto probatório, não restam dúvidas que o réu Rafael possuía as substâncias entorpecentes para fins mercantis.

No caso vertente, têm-se os depoimentos uníssomos dos policiais militares, que fizeram suas declarações com convicção narrando os fatos de forma veemente. Referidos depoimentos, cabe ressaltar, têm valor probatório idêntico àquele prestado por outras pessoas, notadamente se em sintonia com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos.

É ilustrativo o escólio jurisprudencial adiante colacionado, do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“PROVA – Testemunha – Policial – Revestindo-se de inquestionável eficácia o depoimento de servidores policiais, não se pode desqualificá-lo por emanar de agente estatal incumbido da repressão penal, circunstância que não afeta positiva ou negativamente o valor de sua palavra – Recurso não provido.” (Apelação Criminal n. 990.08.040006-1 – Limeira – 16ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Newton Neves – 10.02.09 – V.U. – Voto n. 6224).

Sendo ainda entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal: “É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.” (...) STJ - HC 76.557-RJ 2ª T., rel Carlos Velloso, 04.08.1998.

Saliente-se que, para fins de reconhecimento do delito, desnecessária a comprovação da venda efetiva do entorpecente. A quantidade e a forma de acondicionamento são suficientes para a conclusão de existência de crime de tráfico de entorpecente. Nesse entendimento, para a configuração do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, basta o ato de “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, não se exigindo o ato de mercancia.

No mesmo sentido é o entendimento Jurisprudencial: "Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda. Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de vendada substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo".". (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014).

Nesse raciocínio, importante mencionar as circunstâncias da apreensão, fundamentais a atestar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. De fato, a qualidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína na forma de crack), a quantidade (aproximadamente 1,67 gramas de maconha e 7,45 gramas de crack), a forma de acondicionamento (01 porção de maconha e 60 porções de crack) e a presença de dinheiro em notas diversas (R\$ 400,85), confirmam as denúncias recebidas pelos policiais militares e evidenciam o destino mercantil das substâncias entorpecentes encontradas.

Nesse passo, ainda que se entendesse comprovado que o réu é usuário de drogas, como alegado por ele mesmo, o certo é que tal circunstância não afasta a prática do tráfico. Em outras palavras, o usuário também pode ser traficante.

Vê-se, portanto, que o conjunto probatório, notadamente a confissão do réu Rafael aliada aos depoimentos dos policiais militares tornam certa e inquestionável a materialidade e autoria delitiva quanto ao réu em questão.

Entretanto, conforme se extrai da confissão de Rafael e do conjunto probatório, nada nos autos comprova o envolvimento da corré Regina no tráfico de drogas praticado pelo acusado, sendo de rigor sua absolvição.

Do mesmo modo, incabível o reconhecimento da causa de aumento referente ao art. 40, III, da Lei de Drogas, visto que o conjunto probatório não revela a prática do tráfico de drogas nas dependências ou imediações de estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: "A incidência da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343" (fl. 717)... Em relação à majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, impositivo seu afastamento, uma vez que não restou demonstrado vínculo da conduta dos acusados com as igrejas referidas, tampouco que [...] (STJ - Decisão Monocrática. RECURSO ESPECIAL: Resp. 1973622 - RS (2021/0379368-2)).

Por fim, com relação ao delito de associação de drogas, além do conjunto probatório não demonstrar a existência de vínculo associativo entre os réus voltado ao tráfico de drogas, não se pode ignorar que sequer há provas da participação da corré no tráfico de drogas levado a efeito por Rafael, pelo que impõe a absolvição de ambos os réus quanto à imputação do art. 35, da Lei n. 11.346/2006.

Comprovadas, portanto, a materialidade e autoria delitiva acerca da imputação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 quanto ao réu RAFAEL, um decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo, pois à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, e 42, da Lei de Drogas, observo que as circunstâncias do crime são anormais à espécie. Com efeito, a diversidade e relevante quantidade de entorpecentes apreendidos impõe uma exasperação da reprimenda, pois se trata de tóxico suficiente para atingir grande número de usuários, produzindo, destarte, efeitos danosos gravíssimos à sociedade. Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reapreciando entendimento anterior adotado por esse juízo, incabível a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. "j", do Código Penal, eis que não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do COVID-19.

Nesse mesmo entendimento: "APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes com a recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminosa e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1512067-20.2020.8.26.0228, Rel, Des. Andrade Sampaio, v.u., j. 12.02.2021)

Anoto, contudo, que o réu confessou a prática do crime, configurando a atenuante da confissão, razão pela qual atenuou a pena em 1/6, atingindo 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa – anotando-se a incidência da Súmula 231, do STJ. Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto o réu é tecnicamente primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Vale mencionar que não há provas concretas que caracterizem habitualidade suficiente a afastar o privilégio. Ademais, não é possível utilizar a quantidade de entorpecentes encontrada para afastar o privilégio sob pena de bis in idem.

Dito isso, diminuo a reprimenda em 1/6, perfazendo 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e 485 dias-multa.

Em razão da natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecente, e das circunstâncias judiciais desfavoráveis supracitadas, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, eis que o tráfico de entorpecentes se trata de ilícito penal equiparado aos crimes hediondos. Por identidade de razões, incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por incompatibilidade lógica.

O réu poderá, contudo, recorrer em liberdade, eis que ausentes os requisitos para decretação da custódia cautelar.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por meio da presente ação penal para:

a) ABSOLVER RAFAEL ANSELMO PONTES, qualificado nos autos, da imputação do art. 35, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

b) ABSOLVER REGINA MARIA DE CASTRO FEITOSA, qualificada nos autos, da prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma dos artigos 29, caput, e artigo 35 da Lei nº 11.343/06, ambos combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "j", e na forma do artigo 69 do

Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

c) CONDENAR RAFAEL ANSELMO PONTES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de provas de que o acusado possui boas condições financeiras.

A pena imposta ao réu RAFAEL deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. O acusado poderá recorrer em liberdade. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Inexistindo demonstração da procedência lícita do dinheiro e do aparelho celular periciado às fls. 186/206 apreendidos (fls. 12/13), conclui-se que se tratam de produtos do tráfico de entorpecentes, razão pela qual decreto o perdimento, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06.

De outro vértice, diante da absolvição da ré, defiro a restituição do aparelho celular apreendido nos autos às fls. 12/13 e periciado às fls. 166/185, nos termos do artigo 118 e ss. do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao "Senad" quanto ao perdimento acima mencionado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Condeno o réu Rafael ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, o disposto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo que eventual detração penal deverá ser postulada perante o juízo da execução penal.

Transitada em julgado a presente decisão, comunique-se a Justiça Eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

P.R.I.

Birigui, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA